

1504621-92.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... havendo clara hipótese, ao menos, de tráfico pelo verbo nuclear "trazer", que se trata de delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto em posse da determinada pessoa.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: a variedade, a quantidade e forma de acondicionamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504621-92.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504621-92.2022.8.26.0228, c. 257/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação  
de Prisão em Flagrante - 2054121/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23237565 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2054121 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DIAS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

LEANDRO DIAS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 04h, na Rua Helvética, nº 04, Santa Cecília, São Paulo - SP, trazia e transportava, para fins de tráfico, 01 porção de crack, pesando 50,2g, e 09 porções de cocaína, pesando 5,7g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em 04 de março de 2022 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação da defesa prévia (fls. 90/93).

O réu foi notificado (fls. 141) e ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 155/164). A denúncia foi recebida (fls. 165) e o réu

devidamente citado na presente data.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo em seguida o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a elevação da pena-base pelo mau antecedentes, o reconhecimento da reincidência, não incidência do redutor e a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, destacando a existência de contradições nos depoimentos prestados. Subsidiariamente, requereu a manutenção das penas no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, 4º, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

Os guardas civis metropolitanos narraram que no dia dos fatos estavam estacionados em um ponto fixo, na Rua Helvetia, quando observaram o tráfico ocorrendo em uma praça próxima. Havia um grupo de pessoas que parecia estar vendendo drogas a usuários, dentre eles o réu. Viram o réu atendendo algumas pessoas e com elas fazendo movimento de troca de objetos, mas nenhuma dessas pessoas foi abordada. Quando perceberam que estavam sendo observados, os indivíduos dispersaram-se, sendo que o réu colocou objetos em uma mochila e deixou o local. Foram no encalço dele, sendo que ele tentou evitar a abordagem, misturando-se a outras pessoas e até se jogando no chão. Lograram êxito em o abordar. Em revista, encontraram em poder dele a quantia aproximada de R\$ 2.900, que estava em sua maior parte em notas e moedas trocadas, bem com crack e cocaína. O guarda Fabio disse que havia pequena quantia de dinheiro e de droga com o réu, sendo que a maior parte estaria na mochila, enquanto o guarda Victor disse que todo o dinheiro e toda a droga estavam na mochila. O crack estava em uma porção maior e a cocaína estava fracionada. Com o réu havia um facão, que foi entregue no Distrito Policial. O réu inicialmente ficou em silêncio, mas depois apenas afirmou que alguém teria dito a ele para sair correndo. Ele parecia estar sob efeito de drogas. Não se recordam onde ele disse que residia. Ninguém interveio em favor dele. Não o conheciam anteriormente. O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que é usuário e que saiu de uma internação em dezembro do ano passado. Em fevereiro, teve uma recaída e foi ao local dos fatos para comprar drogas, após pedir dinheiro em um farol e conseguir R\$ 7,00. Comprou uma porção de crack e 2 cigarros de maconha. Sentou-se para usar as drogas, quando ouviu gritaria de que havia policiais no local, o que provocou uma correria generalizada. O interrogando ficou parado onde estava e acabou sendo abordado. Consigo havia apenas um cachimbo e um isqueiro. A bolsa com as drogas e o dinheiro foi encontrada no chão, perto de si. Não conhecia os guardas civis metropolitanos que o abordaram.

Inicialmente, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais, porquanto o artigo 301 do Código Penal é claro ao dispor que qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante delito. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do C. STJ:

"(...) I - É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). II - O v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. De fato, afere-se dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protraí-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a

permanência (precedentes). III - In casu, os guardas civis, durante patrulhamento de rotina, avistaram o ora agravante em local já conhecido como ponto utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e, por ter o acusado apresentado nervosismo ao deparar-se com a viatura, decidiram os agentes por abordá-lo, momento em que localizaram em sua posse 15 (quinze) porções de maconha (fls. 204-205). Indagado a respeito de todo o contexto, o então suspeito admitiu que estava realizando o comércio espúrio, bem como que detinha entorpecentes em sua residência para fins de comercialização (fl. 205), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Nesse compasso, compreende-se igualmente que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. (...) Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 678.534/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021) Ademais, cumpre destacar que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade na abordagem realizada, porquanto existiam fundamentos para sua realização, eis que dotados do poder de polícia inerente às suas atividades, notaram que o réu, em local conhecido como ponto de venda de drogas, procurou se esconder ao notar a viatura, levantando fundada suspeita acerca de eventual conduta ilícita e legitimando a pronta atuação dos guardas. Neste sentido:

"(...) 2. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser "legítima" a abordagem policial questionada, tendo em vista o local e o horário em que o paciente foi abordado, não cabe a Esta Corte análise acerca da alegada ausência de "fundada suspeita", na medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes (...)" (HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Vale destacar, ainda, que os guardas de pronto encontraram, durante a revista pessoal, as drogas informadas nestes autos, além da relevante quantia de R\$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em dinheiro, havendo clara hipótese, ao menos, de tráfico pelo verbo nuclear "trazer", que se trata de delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto em posse da determinada pessoa.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: a variedade, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo; as circunstâncias da prisão em flagrante, com a consequente abordagem do réu em local conhecido como ponto de venda de drogas, a iminente tentativa de fuga ao notar a presença da viatura e o fato de, além das drogas, ter sido encontrada relevante quantidade de dinheiro em espécie; a incompatibilidade entre a quantidade de droga e de dinheiro com a situação financeira declarada pelo réu, que estaria desempregado; observação pelos guardas civis metropolitanos do réu, juntamente com outros indivíduos, em uma espécie de banca, procedendo à venda de drogas; a ausência de demonstração que as drogas destinavam-se para seu consumo próprio, tendo em conta a variedade de drogas e a quantidade, além do fato de que não possuía qualquer apetrecho destinado ao uso dos entorpecentes; o réu não reside nas proximidades, conforme endereço declarado nos autos, o qual fica a quase 40 minutos de carro do local dos fatos. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu

qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido. PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câm. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os guardas ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

Observo que as pequenas contradições havidas em seus depoimentos apenas denotam que prestaram declarações verdadeiras, sem que tenha havido prévio ajuste, sendo certo que as contradições havidas dizem respeito a pontos marginais e não essenciais à diligência. Anoto que não é de se considerar que tenha havido absoluta contradição entre os depoimentos da fase policial e os prestados nesta data, pois é nítido que aqueles constantes da fase inquisitorial são demasiadamente curtos, sem quaisquer detalhes. Houve sim menção sobre a existência de uma banca. De outra banda, na presente data o que os guardas civis metropolitanos relataram não se tratou de uma verdadeira campana, pois estavam em um ponto de estacionamento, do qual puderam observar a movimentação na praça.

No mais, a versão apresentada pelo réu restou isolada, inexistindo qualquer aspecto a comprovar seu enredo, que sequer se mostra verossímil e apto a infirmar a prática do tráfico de drogas relatada pelos policiais.

Ainda que se argumente sobre o fato dos policiais não terem presenciado a comercialização, irrelevante tal aspecto, haja vista que se trata de crime de conteúdo múltiplo ou variado, sendo que no presente caso trazia as porções das drogas supramencionadas.

As substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 101/103), também a corroborar o contido na denúncia.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima referidos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza excepcionalmente nociva dos entorpecentes (cocaína e crack), em diversas porções destinadas à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo, bem como se trata de réu detentor de maus antecedentes (30ª VC, autos 0094113-93.2000.8.26.0050, com pena extinta pelo cumprimento em 04/10/2005 - fls. 126/127 e 136), razão pela qual majoro a pena-base do réu em 1/5, ficando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STF é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Por outro lado, deixo de considerar a condenação referente aos autos 0029779-84.1999.8.26.0050, da 17ª VC, como mau antecedente, porquanto a pena foi extinta pelo indulto em 05/10/2000 (fls. 126 e 135), ou seja, há mais de 20 anos. É certo que se o prazo prescricional máximo é de 20 anos, não se justifica a consideração de condenações extintas em período superior, ainda, como mau antecedente. Neste

sentido, inclusive, o STJ decidiu no REsp 1.875.382 que condenações muito antigas estão amparadas pelo "direito ao esquecimento".

Na segunda fase, ausentes atenuantes, trata-se de réu reincidente (22ª VC, autos 1524444-57.2019.8.26.0228, com trânsito em julgado para a defesa em 18/11/2019 - fls. 127), motivo pelo qual as penas serão elevadas em 1/6, ficando em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que se trata de réu reincidente.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, a gravidade em concreto do delito em questão justifica o regime fechado, tendo em conta a quantidade e variedade dos entorpecentes, representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, somados ao fato do réu ser reincidente, não se justifica outro regime, que não o fechado, como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LEANDRO DIAS PEREIRA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vindo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a sua reincidência e que tornou a delinquir em liberdade, aspectos que apenas ratificam que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 165. Oficie-se para destruição da droga apreendidas.

Tendo em vista que o dinheiro encontrado com o réu não teve sua origem lícita demonstrada nos autos, estando nitidamente atrelado ao tráfico de entorpecentes, em razão da sentença condenatória ora proferida, determino seu perdimento nos termos da lei. Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para

comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070064-900.

P.R.I.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA